



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009371/2019-02 (RJ2019/7413) *

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 04/05/2021

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:

Ricardo Mottin Júnior

Ernani Catalani Filho

Luiz Alcemar Baumart

Ementa: Responsabilidade de administradores da Recrusul S.A. por supostas irregularidades em operação de aumento de capital. Infração ao art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976 e ao art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de:

a) Ricardo Mottin:

a.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976 e art 2º, IX do Anexo 30- XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e

a.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976;

b) Ernani Catalani:

b.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), por violação ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976 e art 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e

b.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976;

c) Luiz Baumart

c.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), por violação ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976 e art 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e

c.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976.

Presente o advogado Fellipe Bernardes da Silva, representando os acusados.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 18/05/2021, às 15:33, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 18/05/2021, às 17:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 18/05/2021, às 19:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1258907** e o código CRC **1CB46726**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1258907** and the "Código CRC" **1CB46726**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009371/2019-02

Reg. Col. nº 1963/20

Acusados: Ricardo Mottin Júnior
Ernani Catalani Filho
Luiz Alcemar Baumart

Assunto: Apuração de responsabilidade de administradores da Recrusul S.A. por supostas irregularidades em operação de aumento de capital. Infração ao art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976 e ao art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I. Objeto e origem

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de Ricardo Mottin Júnior (“Ricardo Mottin”), Ernani Catalani Filho (“Ernani Catalani”) e Luiz Alcemar Baumart (“Luiz Baumart”), em conjunto “Acusados”, na qualidade de membros do conselho de administração da Recrusul S.A. (“Recrusul” ou “Companhia”), por terem aprovado, na reunião do conselho de administração realizada em 01.11.2018, o encaminhamento de proposta de aumento de capital com preço de emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais com deságios não justificados pelas condições de mercado, bem como sem explicar pormenorizadamente a escolha do critério adotado, o que teria ocasionado a diluição injustificada dos antigos acionistas.

2. Este processo teve origem no Processo CVM nº 19957.010200/2018-37 (“Processo de Origem”), que analisou a operação de aumento de capital por subscrição particular de novas ações além do limite do capital autorizado, nos termos do estatuto social da Recrusul, aprovada em reunião do conselho de administração realizada em 01.11.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. Dos Fatos

3. Em 07.01.2016, foi firmado um acordo com credores (“Plano de Pagamentos”)¹, como parte da renegociação de créditos após a recuperação judicial da Recrusul. Aos credores foi concedida a opção de receber recursos provenientes da alienação da sede da Companhia ou da capitalização de créditos com subscrição de ações.

4. Em 01.11.2018, foi realizada reunião do conselho de administração, na qual se propôs a convocação de assembleia geral extraordinária (“AGE”) para a deliberação sobre aumento do limite do capital, o que originou a divulgação, em 05.11.2018, de fato relevante com informações sobre a proposta do aumento de capital a ser deliberada na AGE de 22.11.2018 (“Aumento de Capital”), conforme requerido pelo Anexo 14 da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481”), e tendo como características²:

- (i) aumento de capital no valor de R\$ 95.501.849,85, com a emissão de 70.742.111 novas ações (23.706.183 ações ordinárias e 47.035.928 ações preferenciais) ao preço de emissão unitário de R\$ 1,35 (independentemente da espécie), fixado nos termos do art. 170, §1º, III, da Lei nº 6.404/1976, a partir da cotação média das ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia nos 90 (noventa) últimos pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Sobre tal valor foi aplicado um deságio médio de 7,5% para as ações preferenciais e de 60% para as ações ordinárias, com a finalidade de motivar os atuais acionistas a exercerem seu direito de subscrição, o que seria justificado, principalmente no caso das ações ordinárias, por sua baixa liquidez no mercado;
- (ii) após o aumento de capital - cujos objetivos seriam (a) a necessidade de cumprimento do Plano de Pagamentos com a conversão de dívidas em ações e a consequente amortização de passivos críticos à continuidade dos negócios; e (b) a viabilização de recursos para a alocação em capital de giro, com a finalidade de dar continuidade ao crescimento das operações em 2019 - o capital social da Recrusul passaria para até R\$ 220.000.000,00, dividido em 25.408.950 ações ordinárias e 50.414.424 ações preferenciais;
- (iii) as ações a serem emitidas fariam jus a todos os direitos e vantagens concedidos às já existentes, incluindo dividendos e eventuais remunerações

¹ Doc. SEI 0876038.

² Doc. SEI 0854662.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de capital que viessem a ser declarados pela Companhia após a homologação do aumento de capital pela assembleia geral. Tal homologação poderia ser realizada parcialmente, respeitando o limite mínimo de 50% do valor total da operação;

(iv) cada acionista detentor de ações ordinárias e de ações preferenciais teria o direito de subscrição de 0,93 novas ações para cada ação em seu nome no encerramento do pregão da B3 de 22.11.2018, independentemente da espécie. O prazo para o exercício do direito de preferência seria de 30 (trinta) dias corridos (de 23.11.2018 a 23.12.2018). O acionista que optasse por não exercer esse direito teria seu capital potencialmente diluído em 93,29855%; e

(v) as partes relacionadas que detinham o controle da Companhia teriam se comprometido a subscrever e integralizar, em moeda corrente nacional ou em créditos, o valor mínimo de R\$ 32 milhões³.

5. Em 26.04.2019, foi realizada assembleia geral extraordinária em que foi, entre outros assuntos (i) homologada a operação de aumento de capital; e (ii) deliberada a atualização do estatuto social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital⁴.

6. Por meio dos Ofícios nº 4/2019/CVM/SEP/GEA3, de 11.01.2019, e nº 122/2019/CVM/SEP/GEA3, de 24.05.2019, a SEP solicitou à Companhia informações sobre o Aumento de Capital, em especial uma explicação pormenorizada do critério adotado para a fixação do preço de emissão das novas ações e se o critério escolhido teria sido resultado de uma negociação entre a Companhia e seus credores⁵.

7. Em seus esclarecimentos, a Companhia repetiu a justificativa constante da proposta da administração⁶ e ressaltou que o critério escolhido não havia sido objeto de negociação com os credores da Companhia⁷:

“Não se aplica a elaboração de laudos, mas sim estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão como descrito a seguir. Os critérios de cotação, patrimonial e perspectiva de rentabilidade futura, previstos no artigo 170 §1º da

³ Doc. SEI 0633052.

⁴ Doc. SEI 0854662.

⁵ Doc. SEI 0854662, páginas 31-32 e 47-48.

⁶ Doc. SEI 0854662, página 35.

⁷ Doc. SEI 0854662, página 52.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Lei 6404/76, não parecem adequados no caso da Companhia em sua situação atual pois o patrimônio líquido da Companhia é negativo devido aos sucessivos prejuízos apresentados e pela “limpeza de balanço” orientada pelos seus auditores independentes.

Com base nas médias dos negócios nos últimos 90 dias, os preços praticados foram de R\$ 3,38 por Ação Ordinária e R\$ 1,46 por Ação Preferencial. Aplicamos um deságio de 7,5% no preço da ação preferencial em função da liquidez, perfil da Companhia e aderência dos credores a um preço que refletisse o risco da transformação de seus passivos em equity da Companhia.

Com base neste preço das ações preferenciais, alinhamos o mesmo preço para as ações ordinárias cuja liquidez é bastante restrita em função de representar ações com direito a voto e riscos inerentes ao negócio e, atualmente, mais profundamente pelas interpretações judiciais que envolvem as ações com direito a voto e sua possível e provável responsabilidade solidária de tais acionistas em relação às demandas de passivos judiciais da Companhia optou-se por não onerar, mais do que já está sendo onerado, tais acionistas que subscrevam esta classe de ações.”

8. Tendo considerado insuficientes os esclarecimentos prestados pela Companhia, a SEP enviou aos administradores presentes à reunião do conselho de administração realizada em 01.11.2018, na qual foram aprovados os termos da operação de Aumento de Capital⁸, ofícios (“Ofícios”)⁹ solicitando a manifestação dos Acusados sobre o deságio aplicado no preço das novas ações ordinárias e eventual diluição injustificada dos acionistas não subscritores.

9. Em resposta conjunta datada de 07.11.2019, Ricardo Mottin e Luiz Baumart alegaram, em resumo, que (i) a motivação da Companhia teria sido baseada tão somente em questões de mercado, considerando a baixa liquidez das ações ordinárias, em comparação às ações preferenciais; (ii) não teria havido qualquer negociação com credores para a precificação das ações emitidas; e (iii) utilizando-se de seu poder discricionário, o conselho de administração teria adotado o critério que entendeu mais adequado ao cenário da Companhia, tendo explicitado o referido critério no aumento de

⁸ Doc. SEI 0854662.

⁹ Ofício nº 222/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. SEI 0856369), Ofício nº 223/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. SEI 0856364) e Ofício nº 224/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. SEI 0856367), todos de 09 de outubro de 2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

capital, que foi aprovado pela unanimidade dos acionistas ordinários presentes na assembleia¹⁰.

10. De acordo com a SEP, até a lavratura da peça acusatória, Ernani Catalani não havia apresentado resposta ao Ofício.

11. Porém, em manifestação complementar às razões de defesa apresentadas pelos Acusados, foi esclarecido que a resposta de Ernani Catalani ao Ofício fora encaminhada à CVM tempestivamente, tendo sido juntado aos autos o protocolo da documentação que teria sido enviada¹¹ e a referida resposta ao Ofício¹², em anexo à manifestação complementar da defesa¹³.

12. Ernani Catalani, em sua resposta ao Ofício, além de discorrer sobre o histórico da Recrusul e sobre o processo de recuperação judicial a que se submeteu a Companhia, alegou, resumidamente, que (i) a diluição dos acionistas foi justificada, uma vez que o aumento de capital foi benéfico para a Companhia, tendo havido aumento do patrimônio dos acionistas não subscritores; (ii) o deságio aplicado ao preço das ações seria necessário para cumprir o objetivo de redução de passivos e captação de recursos de que a Companhia necessitava e se justificava em razão da baixa liquidez das ações, além de ser necessário para tornar o negócio atrativo.

III. Conclusões da Acusação

13. Após analisar os esclarecimentos oferecidos pela Companhia e pelos Acusados, a SEP entendeu que a Companhia não justificou adequadamente o deságio aplicado ao preço das ações ordinárias emitidas no âmbito do aumento de capital e a eventual diluição injustificada dos acionistas subscritores, tendo atuado em desacordo com o art. 170, §§ 1º e 7º¹⁴, da Lei nº 6.404/1976 e com o art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009¹⁵.

¹⁰ Doc. SEI 0876034.

¹¹ Doc. SEI 0940060.

¹² Doc. SEI 0940059.

¹³ Doc. SEI 0940057.

¹⁴ “Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações:

§ 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; II - o valor do patrimônio líquido da ação; III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. Sustenta também a Acusação que seria razoável supor que a administração envidou esforços para aprovar o Aumento de Capital com o objetivo de atender aos anseios dos credores, na medida em que se tratava de uma capitalização de créditos detidos em face da Companhia, aprovada de acordo com o Plano de Pagamentos.

15. Nessa linha, argumenta que o preço de emissão das ações a um preço médio excessivamente inferior ao preço médio de cotação não seria justificável, mesmo em face da necessidade de a Companhia sanear as suas dívidas, buscando a sua recuperação financeira, ressaltando que, conforme informado pela Companhia, a diluição potencial dos acionistas que não subscreveram o Aumento de Capital foi de 93,29%.

16. Desta forma, a Acusação concluiu que os Acusados aprovaram encaminhar à assembleia proposta de aumento de capital cujo preço de emissão das ações ordinárias e preferenciais embutiam deságios não justificados pelas condições de mercado, assim como entendeu que não foi apresentada explicação pormenorizada acerca dos aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério adotado para a definição do preço de emissão.

17. Não foi apresentada manifestação técnica complementar acerca das razões de defesa, na forma do art. 38 da Instrução CVM nº 607/2019.

IV. Manifestação da PFE

18. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou-se pela adequação do Termo de Acusação quanto aos requisitos formais constantes dos incisos do art. 6º da Instrução CVM nº 607/2019 e quanto ao atendimento da exigência prevista no *caput* do art. 5º do citado normativo¹⁶.

V. Defesa

19. Os Acusados apresentaram defesa conjunta¹⁷.

20. A defesa alega que a única premissa utilizada pela Acusação para considerar ilícito o deságio aplicado ao preço de emissão das ações no Aumento de Capital seria de

§ 7º A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”

¹⁵ “Art. 2º. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor deve: (...) IX – caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado.”

¹⁶ Doc. SEI 0906537.

¹⁷ Doc. SEI 0937758.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que sua fixação se deu em razão de negociação entre a Companhia e seus credores, no âmbito do Plano de Pagamentos aprovado em 07.01.2016.

21. Nessa linha, sustenta que em nenhum momento a fixação do preço de emissão das ações do Aumento de Capital foi objeto de deliberação pelos credores no âmbito do Plano de Pagamentos.

22. Aduz, dessa forma, que a motivação da Companhia foi baseada tão somente em questões de mercado, considerando a baixa liquidez das ações ordinárias em comparação às ações preferenciais.

23. Ademais, sustenta a defesa que somente as ações preferenciais foram objeto de capitalização de créditos pelos credores da Recrusul, não havendo, portanto, qualquer interesse por parte dos credores da Companhia na determinação do preço de emissão das ações ordinárias no aumento de capital.

24. A defesa reconhece que a determinação do preço de emissão das ações da Companhia era de competência do conselho de administração, conforme disposto no estatuto social. Porém, argumenta que a referida proposta foi aprovada em assembleia geral realizada em 22.11.2018 por todos os acionistas presentes, representativos de 89,35% do capital votante, sem que tenha havido qualquer ressalva.

25. Sustenta que não cabe a esta Autarquia interferir na fixação do preço de emissão das ações, pois a referida determinação de preço estaria no âmbito de discricionariedade da Companhia. Para a defesa, os critérios adotados na fixação do preço foram amplamente justificados e devidamente aprovados pelos acionistas, cumprindo-se, portanto, com o disposto no art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976, bem como no art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009.

26. Segundo a defesa dos Acusados, repetindo o contido na proposta da administração¹⁸, *“os critérios de cotação, patrimonial e perspectiva de rentabilidade futura, previstos no artigo 170 §1º da Lei 6404/76, não parecem adequados no caso da Companhia em sua situação atual pois o patrimônio líquido da Companhia é negativo devido aos sucessivos prejuízos apresentados e pela “limpeza de balanço” orientada pelos seus auditores independentes”*.

27. Assim, o método utilizado para a fixação do preço foi a cotação média dos últimos 90 (noventa) dias das ações preferenciais, aplicando-se um deságio de 7,5%, o

¹⁸ Doc. SEI 08544662.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

qual foi fundamentado no critério de custo de oportunidade do dinheiro balizado pela taxa anual Selic.

28. A defesa alega que em razão da falta de liquidez das ações ordinárias, o preço de emissão para esta espécie de ações foi o mesmo que o fixado para as ações preferenciais, tendo sido aplicado ao caso o disposto no Parecer de Orientação CVM nº 5, de 03.12.1979, utilizando-se *“da regra geral de não empregar preços diferentes para suas ações, uma vez que não estavam atendidos requisitos do PO 05/79”*.

29. Por fim, invoca como circunstâncias atenuantes a ausência de prejuízo ao mercado ou aos demais acionistas, a ausência de dolo e a prestação de informações acerca da materialidade das supostas infrações, bem como requer a produção de prova complementar sem, no entanto, especificá-las e que, em caso de condenação, as infrações imputadas aos Acusados sejam consideradas de natureza leve.

30. Adicionalmente a defesa requereu, em nova manifestação de razões de defesa, que fosse analisada como preliminar de mérito a manifestação de Ernani Catalani em resposta ao Ofício nº 223/2019/CVM/SEP/GEA-3¹⁹, a qual foi considerada pela SEP como não apresentada, conforme anteriormente referido.

VI. Proposta de Termo de Compromisso

31. Os Acusados apresentaram proposta conjunta de celebração de termo de compromisso, na qual sugeriram pagar à CVM o valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de indenização por danos difusos, sendo R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Acusado.

32. A PFE, ao analisar a proposta apresentada, opinou pela inexistência de óbice à sua celebração, destacando que o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) deve *“avaliar a idoneidade dos valores oferecidos para a efetiva prevenção a novos ilícitos e a realização do caráter pedagógico do processo sancionador”*²⁰.

33. Desta forma, o CTC, tendo em vista o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/2019 e o fato de a CVM já ter celebrado termos de compromisso em casos de descumprimento ao art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei 6.404/1976, como, a título de exemplo, no PAS CVM RJ2009/8316, decidiu negociar as condições da proposta apresentada, nos termos do disposto no art. 83, §4º, da Instrução CVM nº 607/2019.

¹⁹ Doc. SEI 0856364.

²⁰ Doc. SEI 0985516.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. Assim, o CTC sugeriu, em 26.05.2020, o aprimoramento da proposta apresentada para o montante total de R\$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), sendo o valor individual de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Ricardo Mottin e Luiz Baumart e R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para Ernani Catalani, “*em razão do seu histórico*”²¹.

35. Os proponentes apresentaram contraproposta²² no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos acusados. Em reunião realizada em 07.07.2020, o CTC decidiu reiterar os termos da negociação deliberada anteriormente, concedendo novo prazo para a manifestação dos proponentes.

36. Os Acusados, no prazo estabelecido pelo CTC, apresentaram nova proposta pontuando as mesmas alegações da proposta anterior, porém, propuseram alterar a proposta conjunta para R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), sendo R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para Ricardo Mottin, R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para Luiz Baumart e R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para Ernani Catalani.

37. Deste modo, considerando os valores propostos e a ausência de novas alegações, o CTC decidiu, em reunião realizada em 28.07.2020, uma vez mais, reiterar os termos da negociação deliberada em 26.05.2020, concedendo novo prazo para manifestação dos proponentes.

38. Os Acusados, porém, não se manifestaram após a deliberação do dia 28.07.2020.

39. Assim, o CTC propôs ao Colegiado a rejeição da proposta conjunta apresentada pelos acusados, considerando, especialmente “*o fato de a proposta final não ser suficiente para o desestímulo de práticas semelhantes*”²³.

40. Em 03.11.2020, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC, decidiu rejeitar a proposta conjunta de termo de compromisso.

²¹ Doc. SEI 1124111.

²² Alegaram resumidamente que: “(i) os valores eram “exorbitantes” e feriam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) “as supostas infrações relativas ao preço de fixação da emissão das ações ordinárias não trouxeram prejuízo aos acionistas”; (iii) houve “agravamento da situação econômico-financeira de todas as companhias, em face da crise do COVID-19”; (iv) o porte da Companhia não condiz com os valores sugeridos, uma vez que se trata de empreendimento regionalizado; e (v) os acusados têm bons antecedentes e demonstraram boa-fé na apresentação das informações solicitadas pela CVM.” (Doc. SEI 1124111).

²³ Doc. SEI 1124111.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VII. Distribuição

41. Em Reunião do Colegiado ocorrida em 03.11.2020 (Reg.1963/20), fui sorteado relator deste processo.²⁴

É o relatório.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente Relator

²⁴ Doc. SEI 1131587.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO RELATÓRIO PTE (Doc. SEI nº 1255254)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1255254.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 05/05/2021, às 16:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1255255** e o código CRC **5BBCD2D0**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1255255** and the "Código CRC" **5BBCD2D0**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009371/2019-02

Reg. Col. nº 1963/20

Acusados: Ricardo Mottin Júnior
Ernani Catalani Filho
Luiz Alcemar Baumart

Assunto: Apuração de responsabilidade de administradores da Recrusul S.A. por supostas irregularidades em operação de aumento de capital. Infração ao art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976 e ao art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I. Introdução

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SEP para apurar a responsabilidade de Ricardo Mottin, Ernani Catalani e Luiz Baumart, na qualidade de membros do conselho de administração da Recrusul, por terem aprovado, em reunião do conselho de administração realizada em 01.11.2018, o encaminhamento de proposta de Aumento de Capital com preço de emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais com deságios não justificados pelas condições de mercado, bem como sem justificar pormenorizadamente a escolha do critério adotado, o que teria ocasionado a diluição injustificada dos antigos acionistas¹.

2. O Aumento de Capital foi deliberado em AGE realizada em 22.11.2018, tendo sido fixado preço de emissão unitário de R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) para as ações ordinárias e preferenciais, nos termos do art. 170, §1º, III, da Lei nº 6.404/1976, com base na cotação média de ambas as espécies de ações de emissão da Companhia, nos 90 (noventa) últimos pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Foi aplicado deságio de 7,5% para as ações preferenciais e de 60% para as ações ordinárias.

3. A justificativa para o aumento de capital, constante da Proposta da Administração, foi a necessidade de dar cumprimento ao Plano de Pagamentos com a

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conversão de dívidas em ações e a consequente amortização de passivos críticos à continuidade dos negócios, assim como a viabilização de recursos para a alocação em capital de giro, com vistas a fomentar o crescimento das operações em 2019.

4. Conforme a proposta do conselho de administração para o Aumento de Capital, o acionista que optasse por não exercer o direito de preferência sofreria diluição de sua participação societária de 93,29%.

II. Preliminar

II.1 Pedido genérico de produção de prova

5. Aprecio preliminarmente o pedido de produção de prova formulado de modo padronizado ao final das razões de defesa, nos seguintes termos: “*seja oportunizada aos exponents a produção de prova documental complementar*”.

6. Noto, no que tange ao referido pedido, que não há qualquer especificação das provas que se pretende produzir, tratando-se, portanto, de pedido genérico que, consoante jurisprudência pacífica desta CVM², não merece ser acolhido.

7. Indefiro, portanto, o pedido de produção de prova documental complementar formulado pelos Acusados.

II.2 Manifestação complementar às razões de defesa

8. No âmbito de manifestação complementar às razões de defesa, mencionada no Relatório, os Acusados requereram que fosse analisada como preliminar de mérito os esclarecimentos apresentados por Ernani Catalani, em resposta ao Ofício nº 223/2019/CVM/SEP/GEA-3³, a qual foi considerada pela SEP como não apresentada.

9. Primeiramente, considero como devidamente cumprido o art. 5º da Instrução CVM nº 607/2019, na medida em que Ernani Catalani foi devidamente notificado para prestar esclarecimentos em 17.10.2019⁴, tendo solicitado à SEP prorrogação do prazo de resposta para 08.11.2019, a qual foi concedida⁵.

² Conforme PAS CVM nº RJ2017/4779, Presidente Relator Marcelo Barbosa, j. em 11.12.2018; PAS CVM nº RJ 2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 03.04.2018 e PAS CVM nº RJ 2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 13.09.2016.

³ Doc. SEI 0856364.

⁴ Doc. SEI 0867447.

⁵ Doc. SEI 0868494.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. Tampouco está claro se a resposta ao ofício não foi juntada aos autos por falha na instrução do processo ou por falha da defesa no envio do documento. Noto que o documento de resposta ao referido ofício, contudo, somente foi juntado aos autos no momento de apresentação de manifestação complementar de razões da defesa, em 14.02.2020, como mencionado no Relatório, apesar de, conforme alegado pela defesa, ter sido protocolado na data aprazada de 08.11.2019⁶.

11. Tendo em vista, porém, que a resposta de Ernani Catalani ao Ofício nº 223/2019/CVM/SEP/GEA-3 foi juntada aos autos durante o prazo para a apresentação da defesa dos Acusados⁷, recebo o documento como se integrasse regularmente a manifestação de defesa e considero, para todos os efeitos, resolvida a presente questão.

III. Mérito

12. A questão controvertida nos autos do presente processo trata do encaminhamento pelos Acusados de proposta de Aumento de Capital cujo preço de emissão das ações ordinárias e preferenciais, determinado com base no que dispõe o artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, aplicou deságios supostamente não justificados pelas condições de mercado.

13. Além disso, a Acusação entendeu que a proposta de Aumento de Capital encaminhada não apresentou justificativa pormenorizada acerca dos aspectos econômicos que fundamentaram a escolha do critério adotado para a definição do preço de emissão, conforme disposto no artigo 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976⁸.

14. Para melhor organização, inicio este voto analisando a alegada ausência de justificativa pormenorizada quanto à escolha do critério para a determinação do preço.

15. De acordo com o sistema da lei societária, a obrigação de apresentação de justificativa pormenorizada se destaca entre os instrumentos de proteção dos acionistas minoritários, uma vez que é autêntico meio de garantir a efetividade do direito essencial previsto no art. 109, IV, da Lei das S.A.⁹.

⁶ Doc. SEI 0940060.

⁷ A data da última intimação para a apresentação de defesa foi em 13.01.2020 e a data do protocolo de juntada do aditamento à defesa foi efetuado em 14.02.2020.

⁸ Art. 170, § 7º: “A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”.

⁹ “Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de:(...)”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. O caráter complementar da regra do art. 170, §1º, em relação ao direito essencial de preferência na subscrição foi reconhecido na Exposição de Motivos da lei societária, que admitiu que o direito de preferência *“nem sempre oferece proteção adequada a todos os acionistas. A emissão de ações pelo valor econômico é a solução que melhor protege os interesses de todos os acionistas, inclusive daqueles que não subscrevem o aumento, e por isso deve ser adotada pelos órgãos competentes para deliberar sobre o aumento de capital.”*

17. Entenda-se bem: o legislador não quis impor à administração das companhias um mecanismo detalhado e demasiadamente prescritivo a ser seguido em aumentos de capital com emissão de ações. A opção foi pela indicação de critérios que podem ser escolhidos de forma isolada ou conjunta, cabendo à administração explicar, pormenorizadamente, na proposta de aumento do capital, *“os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha”*, conforme o art. 170, §7º, já referido.

18. Sendo, em última análise, a obrigação de justificar pormenorizadamente a escolha do critério ou critérios em que a proposta de aumento de capital se fundamentou um mecanismo destinado a permitir aos acionistas a aferição quanto à observância de um direito essencial, caberá à administração cuidar para que a proposta de aumento do capital apresente justificativa realmente pormenorizada – isto é, com as informações necessárias e suficientes que permitam a compreensão e o julgamento – dos critérios escolhidos para amparar a fixação do preço de emissão.

19. Estabelecida esta premissa, passo a tratar, em concreto, da alegação de ausência de justificativa pormenorizada.

20. Nos termos da Proposta da Administração¹⁰, a modalidade escolhida para a fixação do preço de emissão foi a de cotação das ações em bolsa. Compulsando os autos, verifico, conforme aduzido pela Acusação, que não constou da referida Proposta da Administração, nem de qualquer outro documento relacionado à operação de Aumento de Capital¹¹, explicação pormenorizada relativamente aos aspectos econômicos que fundamentaram a escolha do critério adotado (cotação em bolsa).

IV – preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos arts. 171 e 172; (...)

¹⁰ Doc. SEI 0633052, página 5.

¹¹ Reunião do Conselho de Administração de 01.11.2018., na qual se propôs a convocação de assembleia geral extraordinária, Fato Relevante de 05.11.2018 e AGE de 22.11.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

21. Em termos bastante sumários, a administração da Companhia apresentou como justificativa para a não adoção dos outros critérios, previstos nos incisos I e II do §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/1976 – perspectiva de rentabilidade e valor patrimonial da ação – a condição de a Companhia possuir patrimônio líquido negativo:

“Os critérios de cotação, patrimonial e perspectiva de rentabilidade futura, previstos no artigo 170 §1º da Lei 6404/76, não parecem adequados no caso da Companhia em sua situação atual pois o patrimônio líquido da Companhia é negativo devido aos sucessivos prejuízos apresentados e pela “limpeza de balanço” orientada pelos seus auditores independentes.”

22. Assim, ainda que se possa considerar justificada a não adoção do critério do valor contábil, em razão de o patrimônio líquido ser negativo, entendo que restou ausente da Proposta da Administração, ou de qualquer outro documento relacionado à operação de Aumento de Capital, explicação pormenorizada para a não adoção do critério atinente à perspectiva de rentabilidade futura, previsto no inciso I do §1º do art. 170.

23. Mesmo que se considerasse tal critério inadequado em razão da situação de dificuldade financeira vivida pela Companhia, a Administração deveria ter justificado de forma destacada sua escolha de critérios, o que implica explicação sobre o critério ou critérios não adotados – o que, neste caso, significa a eliminação do método de valor presente de fluxo de caixa futuro¹².

24. Nesse diapasão, deve-se mencionar que a perspectiva de rentabilidade é aferida com fundamento na expectativa de geração de riqueza da companhia projetada para o futuro¹³. Por essa razão, entendo que a existência de patrimônio líquido negativo, por si só, não pode ser considerada como justificativa apta para afastar a utilização do método previsto no inciso I do §1º do art. 170, para a determinação do preço de emissão.

25. Novamente, e para que não haja dúvidas, lembro que a escolha dos critérios previstos nos incisos I a III do §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/1976 para a fixação do

¹² Conforme citado por Luiz Alberto Colonna Rosman, Aswath Damodaran “ressalta que há casos – quando os fluxos de caixa não são positivos ou não podem ser estimados para períodos futuros com certo grau de confiabilidade – em que a avaliação pode encontrar dificuldades e necessitar de adaptações, tais como os de (i) sociedades em má situação financeira (cujos fluxo de caixa são negativos), (...)” (Direito das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1026).

¹³ O método de fluxo de caixa livre descontado é o mais usado para retratar a capacidade de geração de riqueza de uma empresa, em um determinado período de tempo, embora haja outros métodos idôneos para a mesma finalidade.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

preço de emissão é discricionária¹⁴, cabendo à administração definir aquele ou aqueles que considere os mais adequados. Contudo, qualquer que seja a escolha, deverá ser objeto de justificativa minudente, e neste caso entendo que não restaram devidamente esclarecidas as razões pelas quais, na visão dos administradores, o critério da cotação em bolsa era o que melhor refletiria o valor real das novas ações a serem emitidas¹⁵.

26. Melhor dizendo, não ficaram evidenciadas as razões pelas quais a Companhia não adotou o critério de expectativa de rentabilidade futura para a fixação do preço de emissão das ações no Aumento de Capital.

27. Na ata da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 01.11.2018, que deliberou sobre o limite do capital autorizado e sobre o encaminhamento da proposta de Aumento de Capital, lê-se:

“**Número de Ações e Preço de Emissão:** emissão de 70.742.112 (setenta milhões setecentos e quarenta e dois mil e cento e doze) novas ações, sendo 23.706.183 (vinte e três milhões setecentos e seis mil cento e oitenta e três) novas ações ordinárias, e 47.035.929 (quarenta e sete milhões trinta e cinco mil novecentos e vinte e nove) novas ações preferenciais, todas sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,35 (hum real e trinta e cinco centavos) por ação ordinária e R\$ 1,35 (hum real e trinta e cinco centavos) por ação preferencial, fixado levando- se em consideração a cotação média das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia ("RCSL3" e "RCSL4") em Bolsa de Valores nos últimos 90 (noventa) pregões da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, aplicando- se um desconto médio de 7,5% para as ações preferenciais e de aproximadamente 60,0% para as ações ordinárias em função da baixa liquidez desta classe e, ainda, apesar de existir uma relação de troca que perdura por vários meses de, aproximadamente, 2:1 entre ações ordinárias e preferenciais, o Conselho de Administração não encontrou razões e fundamentos para tal proporção. Os descontos médios pela qual o Conselho optou em conceder aos atuais acionistas é com o intuito de motivar a todos os acionistas a exercerem seus direitos de subscrição;”

28. Tal redação, que segundo a defesa seria a comprovação de que houve justificativa pormenorizada, conforme exigência do §7º, do art. 170, se repete, *ipsis litteris* no Fato Relevante de 05.11.2018 e na Proposta da Administração, submetida aos acionistas reunidos na AGE¹⁶.

¹⁴ Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada, Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 497; Carvalhosa, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3º Volume – Arts 138 a 205 – 5. Ed. Ver e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 615.

¹⁵ Após a reforma promovida no art. 170 da Lei nº 6.404/1976 pela Lei nº 9.457/1997, passou-se a admitir a adoção isolada de um entre os três critérios para justificar o valor da emissão.

¹⁶ Doc. SEI 0937758.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

29. Ou seja, em nenhum dos documentos relacionados ao Aumento de Capital (que incluem a Proposta da Administração), elaborados para consulta pelos acionistas para sua tomada de decisão quanto à subscrição do aumento de capital, constou explicação pormenorizada sobre a não adoção do critério de expectativa de rentabilidade futura para a fixação do preço de emissão das ações no Aumento de Capital.

30. Desta forma, os argumentos trazidos pela defesa de que “os critérios adotados foram amplamente descritos e justificados, cumprindo com a exigência” do art. 170, §7º, não me convencem.

31. Tampouco me convencem as alegações da defesa, mesmo com fulcro em abalizada doutrina, de que o critério de fixação de preço de emissão com base em cotação em bolsa de valores seria o mais adequado para companhias como a Recrusul, que tenham ações negociadas no mercado bursátil e sejam “dotadas de índices razoáveis de liquidez”¹⁷.

32. Com a devida vênia, ainda que se trate de companhia com ações negociadas em bolsa e dotadas de liquidez, entendo que a justificativa da escolha sobre o critério adotado sempre se impõe em razão de preceito legal, de forma que deveriam ter constado da Proposta da Administração, de forma específica, os motivos que fundamentaram a não adoção do critério de perspectiva de rentabilidade futura.

33. No caso concreto, essa percepção – quanto à ausência de justificativa pormenorizada – se reforça ainda mais em razão da assumida falta de liquidez das ações ordinárias, o que aponta, em um primeiro exame, para a inadequação da escolha do critério de cotação das ações em bolsa, na medida em que essa condição, de falta de liquidez, reflete a pouca relevância deste parâmetro para a aferição do valor efetivo das ações.

34. Na sequência do trecho da doutrina citada pela defesa, acima referido, sobre a adequação da modalidade de cotação em bolsa para a determinação de preço de emissão de novas ações em companhias que tenham ações negociadas em bolsa, o mesmo autor adverte:

“Existe uma presunção absoluta de liquidez das ações que integram os índices da bolsa; com relação às demais, deverá a proposta de aumento de capital demonstrar que apresentam

¹⁷ Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 497-498.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

liquidez suficiente, medida em volume de negócios, seja quanto ao número, seja quanto ao valor, para justificar a escolha de tal critério.”¹⁸ (grifei)

35. Ressalto que a reforma promovida pela Lei nº 9.457/1997, ao acrescentar o § 7º ao art. 170 da Lei nº 6.404/1976, tornou obrigatória a explicitação das razões da adoção de determinado critério ou de sua combinação, com o objetivo de que os atuais acionistas possam supervisionar e fiscalizar a atuação dos administradores e evitar ocorrência de diluição injustificada. Nesta linha, os precedentes desta Autarquia apontam para a necessidade de justificar o critério de escolha para a definição do preço de emissão de novas ações, sendo que tal justificativa deve ir além da mera descrição do que dispõem os incisos I a III do §1º do Art. 170:

“Não basta que sejam apontados os critérios que serviram de base para a fixação do preço de emissão. É necessário explicar, de forma detalhada, o motivo pelo qual se entendeu melhor fixar o preço com base nesse ou naquele critério (ou, em caso de utilização de mais de um critério, as razões de utilização daqueles parâmetros de forma combinada), ou o porquê da não utilização de outro parâmetro entre aqueles elencados nos incisos do §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/1976.”¹⁹

36. Considerando a exigência legal, e seu entendimento pela doutrina e por este Colegiado em casos anteriores, não me parece que a administração da Companhia tenha apresentado justificativa pormenorizada para a escolha do critério adotado na fixação do preço de emissão.

37. Entendo, portanto, que os Acusados descumpriram o disposto no artigo 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976.

38. Passo agora a analisar a atribuição de responsabilidade em razão da aplicação de deságios supostamente em desacordo com as condições de mercado vigentes, ocasionando a diluição injustificada dos acionistas.

39. Alega a Acusação que em razão de o aumento de capital envolver uma capitalização de créditos, conforme previsto no Plano de Pagamentos, seria “*razoável supor*” que a fixação do preço de emissão das ações por preço “*excessivamente*” inferior à cotação média teria tido como objetivo “*atender aos anseios dos credores*”. Nessa linha, argumentam que o fato de a Companhia necessitar de recursos para sanear dívidas

¹⁸ Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 497-498.

¹⁹ PAS CVM nº RJ2013/6294. Dir. Rel. Pablo Renteria. j. em 14.11.2017; no mesmo sentido, PAS CVM nº RJ 2011/11073. Dir. Rel. Pablo Renteria. j. em 15.12.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com o objetivo maior de sua recuperação financeira não seria justificativa para a aplicação dos referidos deságios, os quais implicariam severa diluição dos acionistas que não subscreveram o Aumento de Capital.

40. Não há documento nos autos que comprove que o preço fixado para o aumento de capital decorreu apenas, ou mesmo principalmente, de negociação direta com os credores. Noto, porém, que o Plano de Pagamentos, ao dispor sobre o preço de emissão do Aumento de Capital, excluiu dos parâmetros para a fixação do preço o cálculo de acordo com o valor contábil²⁰.

41. Apesar disso, a celebração do Plano de Pagamentos não pode ser vista como decorrência lógica de que o preço fixado no Aumento de Capital visou atender exclusivamente o interesse de novos acionistas que capitalizaram créditos. O que se pode reconhecer, por óbvio, é que houve negociação com os credores da Companhia, e que seu resultado foi refletido no Plano de Pagamentos. Portanto, o Aumento de Capital foi proposto em termos acordados com os credores. Porém, não se pode simplesmente afastar, como fez a Acusação, a possibilidade de outros fatores além do interesse dos credores terem sido levados em consideração na definição dos termos do Aumento de Capital.

42. Discordo, contudo, dos argumentos trazidos pela defesa, de que toda a Acusação gira em torno de uma “falsa premissa” de que o deságio foi ilícito em razão de o preço de emissão ter sido resultado de uma negociação com os credores. Não há nos autos elementos que amparem tal alegação.

43. Ressalto, ainda, que a defesa nega, peremptoriamente, que tenha ocorrido qualquer tipo de negociação com credores quanto à fixação do preço.

44. Noto, entretanto, que é pacífico o entendimento desta Autarquia de que é legítimo que uma operação de aumento de capital, por meio de capitalização de créditos, seja precedida de negociação entre a companhia, credores e acionistas para a fixação do preço de emissão, na medida em que a subscrição e integralização dos créditos em aumento de capital dependerá de sua concordância quanto ao valor das ações fixado para a nova emissão. Nesse sentido, cito trecho de voto da Diretora Luciana Dias no PAS CVM nº RJ 2009/8316:

²⁰ Doc. SEI 0937762, página 7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“Além disso, sob o ponto de vista prático, em operações de aumento de capital que envolvem capitalização de créditos, como a do caso concreto, a negociação entre as partes interessadas, quais sejam, companhia, acionistas e credores, constitui uma etapa da qual não se pode fugir no procedimento de decisão sobre o aumento de capital em si e fixação do preço de emissão das novas ações. Afinal, a concordância do credor é indispensável para a viabilização da operação, uma vez que os créditos serão transformados em capital e os credores passarão a ser acionistas.”²¹

45. Nessa linha, a discussão sobre se o preço de emissão foi objeto de negociação entre os credores, Companhia e os administradores é irrelevante para o deslinde do caso, pois, como visto acima, a ocorrência de negociação com credores para a fixação de preço de emissão de novas ações em operação de aumento de capital que envolva a capitalização de créditos não implica irregularidade do aumento de capital subsequente.

46. Da mesma forma, reitero que não procedem as alegações da defesa de que toda a acusação se sustenta em falsa premissa de que a fixação do preço de emissão foi ilícita, em razão da suposição de que resultou de negociação empreendida com credores.

47. A peça acusatória, em minha visão, atribui responsabilidade aos administradores por infração ao artigo 170, §1º, em razão de o deságio aplicado às ações ordinárias não ter sido suficientemente justificado, vis a vis as condições de mercado que se apresentavam na época, notadamente em razão do desconto de 60% aplicado sobre o preço médio das ações ordinárias nos 90 pregões que antecederam a fixação do preço, sendo que o Aumento de Capital implicou em uma diluição potencial de 93,29%.²²

48. Sobre esse aspecto, a defesa aduz que a determinação do preço levou em consideração as condições de mercado, levando em conta, principalmente, a baixa liquidez das ações ordinárias, em comparação com as ações preferenciais, tendo citado precedente da CVM nesse sentido²³.

49. A defesa esclareceu que o preço de emissão das ações ordinárias foi composto utilizando como referência a média de negociação das ações preferenciais num período de 90 (noventa) dias anteriores ao Aumento de Capital, em razão de as ações

²¹ PAS CVM nº RJ 2009/8316, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 09.04.2013.

²² “Todavia, a Companhia não justificou suficientemente o deságio aplicado no preço das novas ações ordinárias e eventual diluição injustificada dos acionistas não subscritores, em desacordo com o art. 170, §§ 1º e 7º da Lei 6.404/76 e o art. 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/09.” (Termo de Acusação, § 20. Doc. SEI 0883430).

²³ Processo CVM n.º RJ 2010/16884, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 17.12.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

preferenciais possuírem um volume consideravelmente maior de negociação, refletindo, no seu entender, o real valor da companhia²⁴.

50. Ainda de acordo com as informações trazidas pela defesa dos Acusados, as ações ordinárias possuíam um volume de negociações de apenas 1,71% das ações da Recrusul, enquanto as ações preferenciais possuíam um volume de 98,29% das operações em bolsa e, portanto, segundo alega, não haveria razão para que fossem fixados preços distintos para as ações ordinárias e preferenciais, “*devendo prevalecer o critério mais próximo das ações com maior volume de negócios na bolsa*”²⁵.

51. Ou seja, conforme esclarecido pela defesa, o preço de emissão das novas ações ordinárias teve por base o preço da cotação média das ações preferenciais, computando-se um deságio de 7,5%.

52. Nessa linha, cita o Parecer de Orientação CVM nº 5, de 03.12.1979 (“Parecer de Orientação 05”), para justificar a determinação de preços iguais para ações de espécies distintas pois, em função da baixa liquidez das ações ordinárias, a Companhia teria usado a regra geral do Parecer de Orientação 05 de não empregar preços diferentes na mesma emissão.

53. Não concordo, contudo, com os argumentos trazidos pela defesa no que tange às justificativas para a aplicação de deságio de 60% em relação à cotação das ações ordinárias em bolsa, envolvendo tão elevado potencial de diluição.

54. No precedente citado pela defesa²⁶, analisou-se a seguinte questão: se companhias com duas ou mais espécies ou classes de ações que realizem aumentos de capital podem fixar preços de emissão calculados a partir da média das cotações dessas duas ou mais espécies ou classes.

55. O Relator do referido processo entendeu, em linha com parte da doutrina e precedentes desta Autarquia²⁷, que não há uma rigidez quanto à adoção dos critérios previstos no art. 170, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. Nesse sentido, estes critérios devem ser

²⁴ “Os referidos acionistas compreenderam que o preço de emissão das ações ordinárias foi composto utilizando como referência a média de negociação das ações preferenciais num período de 90 (noventa) dias antes do aumento de capital social, considerando que as ações preferenciais possuem um volume consideravelmente maior de negociação, exprimindo, em maior critério, o real valor da companhia individualmente considerado no preço das ações”. (Doc. SEI 0937758).

²⁵ Doc. SEI 0937758.

²⁶ Processo CVM nº RJ 2010/16884. Dir. Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013.

²⁷ PAS CVM nº RJ 2009/8316. Dir. Rel. Luciana Dias. j. em 09.04.2013;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

levados em consideração como parâmetros para a fixação do preço de emissão como ponto de partida, porém, podem ser ajustados à realidade da companhia e do setor em que atua²⁸.

56. Contudo, é preciso verificar se os ajustes feitos no preço de emissão a partir dos parâmetros estabelecidos no supracitado art. 170 são consistentes, devendo, para tanto, ser considerado o interesse da companhia quanto à obtenção de recursos adicionais para o desenvolvimento dos seus negócios, estabelecendo-se um preço de emissão que seja capaz de incentivar a subscrição das novas ações por investidores ou pelos antigos acionistas²⁹.

57. Portanto, e considerando o interesse social, o preço de emissão deve ser aquele que, no caso concreto, por um lado, motive a subscrição das novas ações e, por outro, alcance o maior valor possível.

58. Nada obstante, e nos termos do já citado precedente, uma vez adotado o critério de fixação do valor de cotação em bolsa ou no mercado de balcão, a determinação do preço deve basear-se nas condições de mercado:

²⁸ “6. Inicialmente deve-se frisar, como já o fez a doutrina, que a lei acionária não estabelece uma fórmula rígida para a fixação do preço de emissão. O que se depreende do texto legal é que o preço das novas ações deve ser estabelecido “tendo em vista” a perspectiva de rentabilidade da companhia, o valor do patrimônio líquido contábil da ação, a cotação das ações no mercado em que forem negociadas ou, ainda, uma combinação entre dois ou três desses valores.

7. A doutrina também reconhece, ante a locução “tendo em vista”, que o poder de fixar o preço de emissão é um poder que se pode caracterizar como discricionário, cujo exercício deve obedecer ao interesse social. É F. K. Comparato quem afirma que aos órgãos responsáveis pela fixação do preço de emissão seria atribuído um poder dessa natureza, uma vez que a eles seria conferido “uma certa latitude,(...) um perímetro decisório (...), um quadro de referências, dentro do qual pode ser determinado(...) [o] preço [de emissão], de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto e em função do interesse societário dos minoritários.”

8. Com base nesses elementos, pode-se descrever, ainda que de maneira um tanto o quanto esquemática, o processo de fixação do preço de emissão da seguinte forma: adota-se, como ponto de partida para a fixação do preço de emissão, o valor correspondente ao(s) critério(s) do § 1º do art. 170 que melhor atenda(m) ao interesse da companhia, utilizando-se, para tal escolha, fundamentos verdadeiros e consistentes acerca da situação da companhia, inclusive em face do setor em que atua.” (Processo CVM n.º RJ 2010/16884. Dir. Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013).

²⁹ “A distinção entre a diluição legítima e ilegítima não pode ser precisada na lei porque pressupõe o conhecimento, em cada caso, das diversas circunstâncias relativas à intensidade do interesse da companhia na obtenção de recursos adicionais, à espécie e quantidade dos subscritores potenciais das novas ações e ao nível de preço de emissão que é necessário fixar para que esses investidores potenciais subscrevam efetivamente o aumento.” (José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, citado por Luiz Alberto Colonna ROSMAN, Direito das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 1023).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“(…) uma vez definido que a cotação das ações será o único parâmetro a se considerar na fixação do preço de emissão (que é o caso do Aumento de Capital), eventuais discrepâncias (ou convergências) devem estar fundamentadas nas tais "condições de mercado". É dizer: nesse caso, e sob pena de se desconsiderar completamente o disposto na parte final do inciso III do § 1º do art. 170, aquele "tendo em vista" do § 1º deve ser concretizado exclusivamente com base nas "condições de mercado".”³⁰

59. Desta forma, por óbvio, soa implausível o argumento trazido pela defesa de que em razão da baixa liquidez do ativo o preço fixado para as ações não poderia seguir exclusivamente os parâmetros de cotação em bolsa, devendo ser considerado, no âmbito do cenário de dificuldade financeira vivido pela Companhia, a necessidade do estabelecimento de preço para as novas ações que fosse atrativo para novos investidores³¹.

60. No caso em exame, as condições de mercado das ações ordinárias e preferenciais eram bastante distintas, notadamente em razão da reconhecida ausência de liquidez das ações ordinárias, o que, necessariamente, implicava que a sua cotação em bolsa não fosse representativa do valor econômico da Companhia.

61. A defesa traz, em seus argumentos que, nos termos do Parecer de Orientação 05, a fixação de preços díspares em uma mesma emissão é a exceção e não a regra e que, em razão da baixa liquidez das ações ordinárias, a Companhia se utilizou da regra geral de não empregar preços diferentes para suas ações, uma vez que não estariam atendidas as condições para o estabelecimento de preços distintos, conforme fixado no Parecer de Orientação 05 – ou seja, (i) apresentação de cotações de mercado significativamente díspares; e (ii) todas possuírem significativos índices de negociabilidade.

62. A par do já fixado entendimento de que a escolha dos critérios previstos nos incisos I a III do §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/1976 é discricionária³², uma questão que se coloca, a meu ver, é se seria legítima a adoção do critério de cotação em bolsa ou

³⁰ Processo CVM n.º RJ 2010/16884. Dir. Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013.

³¹ Conforme manifestação complementar às razões da defesa (Doc. SEI 0940059).

³² “Por último, como nenhum órgão regulador do mercado de valores mobiliários deve arvorar-se em avaliador de preços de mercado, não será intenção da CVM pretender entrar no mérito do preço de emissão de ações, interferindo, deste modo, no mercado. O que a CVM exigirá, no entanto, é que o preço de emissão das novas ações seja sempre justificado, de maneira clara e precisa, por ocasião da assembléia geral que deliberar sobre a autorização do aumento de capital. Se atribuída à fixação de tal preço ao conselho de administração da companhia, a justificativa do preço deverá constar, igualmente clara e precisa, do parecer que vier a ser expedido pelo Conselho.” (Parecer de Orientação nº 1, de 27.09.1978)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

no mercado de balcão, quando somente uma espécie de ação possui liquidez, em aumento de capital efetuado com a emissão de mais de uma espécie de ação.

63. Neste sentido, ressalto que o Parecer de Orientação 05 dispõe que *“se ínfimo o índice de negociação de um dos tipos de ações no mercado, logicamente será inexpressivo o parâmetro “cotação de mercado” como fator a ser considerado para a fixação do preço daquele tipo de ação.”*

64. Noto, além disso, que esta Autarquia já reconheceu que é cabível a utilização do critério de fixação de preço previsto no art. 170, §1º, inciso III, quando a companhia possui ações sem liquidez no mercado³³.

65. Não obstante, naquele caso, conforme esclarecido no voto do Relator, foi levado ao conhecimento dos acionistas estudo que fundamentou a fixação do preço de emissão, onde constou que não seria possível nem a fixação do preço de emissão com base na perspectiva de rentabilidade futura, considerando o prejuízo da companhia na época, a geração de caixa negativo e a projeção de resultados que se apresentou negativa, sem possibilidade de fixação de qualquer prognóstico, nem a adoção de valor patrimonial, por esse ser descolado do valor de mercado, o que tornaria não atrativa a subscrição das ações.

66. No caso em exame, conforme já mencionei, a exclusão do critério de expectativa de rentabilidade futura, previsto no inciso I do §1º do art. 170 da Lei nº 6.404/1976, não foi justificada com base em estudo apresentado aos acionistas, nem fundamentada na Proposta da Administração ou nos demais documentos relacionados ao Aumento de Capital.

67. Voltando-se para a questão do critério do cálculo de preço de emissão das ações com base nas condições de mercado, nas informações adicionais sobre o Aumento de Capital da Proposta da Administração, no item X³⁴, constou apenas que:

“(…) Com base nas médias dos negócios nos últimos 90 dias, os preços praticados foram de R\$ 3,38 por Ação Ordinária e R\$ 1,46 por Ação Preferencial. Aplicamos um deságio de 7,5% no preço da ação preferencial em função da liquidez, perfil da Companhia e aderência dos credores a um preço que refletisse o risco da transformação de seus passivos em equity da Companhia.

³³ Processo CVM nº RJ2006/0180, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. em 11.04.2006.

³⁴ Doc. SEI 0854662, páginas 10-11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Com base neste preço das ações preferenciais, alinhamos o mesmo preço para as ações ordinárias cuja liquidez é bastante restrita em função de representar ações com direito a voto e riscos inerentes ao negócio e, atualmente, mais profundamente pelas interpretações judiciais que envolvem as ações com direito a voto e sua possível e provável responsabilidade solidária de tais acionistas em relação as demandas de passivos judiciais da Companhia optou-se por não onerar, mais do que já está sendo onerado, tais acionistas que subscrevam esta classe de ações”.

68. Ao que parece, o conselho de administração, ao encaminhar a Proposta da Administração prevendo que o preço de emissão das ações ordinárias seria o mesmo das ações preferenciais, não levou em consideração o interesse da Companhia de captar o máximo de recursos ao menor custo de capital possível.

69. Não obstante, para efeito da responsabilidade imputada aos Acusados no presente processo, constato que o critério de cálculo do preço das ações ordinárias não foi devidamente justificado, notadamente pelo elevado deságio aplicado sobre o valor da média da cotação destas ações, em patamar muito superior aos parâmetros que normalmente são praticados³⁵ e envolvendo elevado potencial de diluição dos acionistas (93,29%), não tendo sido observadas as condições de mercado para a fixação do preço.

70. Nessa linha, noto que tampouco o deságio aplicado às ações preferenciais foi devidamente justificado. Embora a defesa alegue que o referido deságio de 7,5% foi aplicado considerando o custo de oportunidade balizado pela Taxa Selic, essa explicação não constou da Proposta da Administração, nem dos documentos relacionados ao Aumento de Capital, mas tão somente da resposta aos Ofícios nº 4/2019/CVM/SEP/GEA3, de 11.01.2019, e nº 122/2019/CVM/SEP/GEA3, de 24.05.2019³⁶, apesar de a defesa alegar que tal informação consta na página 7, item d, da Proposta da Administração³⁷.

71. Conforme esta Autarquia já se pronunciou³⁸, a justificativa pormenorizada do critério adotado para a fixação do preço, conforme exigência do §7º do art. 170, da Lei

³⁵ “O Tribunal julgou legal o aumento, entendendo que o preço de emissão das novas ações estava correto e refletiu a realidade do mercado, situando-se o deságio nos parâmetros admitidos pela CVM (20%).” (Rosman, Luiz Alberto Colonna, Direito das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1023). Nesse sentido, sobre o parâmetro de 20% para a aplicação de deságios em relação a cotação das ações, ver Processo CVM n.º RJ 2010/16884. Dir. Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013.

³⁶ Doc. SEI 0854662, páginas 35-36 e 51-52.

³⁷ Doc. SEI 0937758.

³⁸ PAS CVM RJ 2009/2610, Dir. Rel Marcos Barbosa Pinto, j. em 28.09.2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nº 6.404/1976, deve ser fornecida previamente ao aumento de capital. A meu ver, o mesmo entendimento se aplica quando se trata do critério do cálculo do preço de emissão, uma vez que essa explicitação cumpre idêntico papel, de possibilitar a fiscalização e supervisão de aumentos de capital por parte dos acionistas minoritários, com o objetivo de evitar diluições ilegítimas³⁹.

72. Ademais, e conforme esclarecido, entendo que uma vez adotado o critério previsto no inciso III do §1º do art. 170, a fixação do preço deve basear-se tão somente nas condições de mercado.

73. Assim, a meu ver, o que caracteriza, nesse caso, a violação do comando legal, é a não explicitação do critério de cálculo de preço de emissão das ações na Proposta da Administração e nos demais documentos do Aumento de Capital, com a aplicação de expressivo deságio sobre a cotação das ações ordinárias, que além de implicar em severa diluição potencial dos acionistas (93,29%), elevou sobremaneira o custo de capital dos recursos captados.

74. Desta forma, entendo que o critério do cálculo do preço de emissão das novas ações ordinárias e preferenciais, notadamente quanto aos deságios aplicados, não foi justificado com base nas condições de mercado.

75. Noto, ainda, que as alegações dos Acusados de que o Aumento de Capital foi aprovado por 89,35% do capital votante e que nenhum acionista se insurgiu quanto ao critério adotado pela Companhia para a fixação do preço não tem o condão de eximir os administradores das violações aos §§ 1º e 7º do art. 170 da Lei nº 6.404/1976, conforme já decidido por esta Autarquia⁴⁰.

³⁹ “(...) A distinção entre a diluição legítima e ilegítima não pode ser precisada na lei porque pressupõe o conhecimento, em cada caso, das diversas circunstâncias relativas à intensidade do interesse da companhia na obtenção de recursos adicionais, à espécie e quantidade dos subscritores potenciais das novas ações e ao nível de preço de emissão que é necessário fixar para que esses investidores potenciais subscrevam efetivamente o aumento.” (Direito das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1023).

⁴⁰ PAS CVM nº RJ2013/11113, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.08.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. Conclusão e dosimetria

76. Por todo o exposto, concluo que os Acusados, na qualidade de membros do conselho de administração da Recrusul, violaram o art. 170, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.404/1976 e o art. 2º, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009.

77. Passo, assim, à dosimetria das penas, considerando que as infrações foram praticadas após a edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017.

78. Noto que esta Autarquia já aplicou reiteradamente a penalidade de advertência em relação ao descumprimento do §7º do art. 170, da Lei nº 6.404/1976. Não obstante, nesses precedentes, ou não houve acusação de diluição injustificada, com base no §1º do mesmo dispositivo, ou a conclusão do voto foi pela absolvição quanto a essa imputação.⁴¹

79. No caso em exame, porém, entendo que, diferente dos precedentes citados, justifica-se a aplicação da penalidade de multa pela infração ao citado §7º, na medida em que a inobservância da regra imposta por este dispositivo da Lei Societária está intimamente ligada ao descumprimento do §1º do mesmo dispositivo.

80. Ademais, observo que após a edição da Instrução CVM nº 607, de 17.06.2019, as infrações administrativas em questão passaram a constar do Grupo III do Anexo 63 da referida norma, cuja penalidade máxima foi estipulada em R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)⁴².

81. Diante disso, fixo as penas-base de Luiz Baumart e Ricardo Mottin em: (i) R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976 e ao art 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e (ii) R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976.

82. Ernani Catalani, entretanto, é reincidente⁴³ e, portanto, no seu caso, o valor máximo da multa aplicável poderia ser de até o triplo dos valores fixados no art. 61 da

⁴¹ PAS CVM nº RJ2013/6294, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 14.11.2017; PAS CVM nº RJ 2011/11073. Dir. Rel. Pablo Renteria. j. em 15.12.2015; PAS CVM nº RJ 2009/8316. Dir. Rel. Luciana Dias. j. em 09.04.2013; PAS CVM Nº RJ2012/7767, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 02.04.2013.

⁴² Anexo 63, infrações administrativas do grupo III: “I – relacionadas à fixação do preço de emissão em sede de aumento de capital social de companhia aberta mediante subscrição de ações.”

⁴³ Condenação com trânsito em julgado em 27.09.2016, cf. Ficha de Antecedentes emitida em 05.04.2021 pela Divisão de Controle de Processos Administrativos – CCP (condenado a penalidades de multa por (i) convocar intempestivamente a assembleia geral ordinária relativa aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 2013, em infração ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404, de 1976; e (ii) por não entregar as propostas da administração para as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Instrução CVM nº 607/2019⁴⁴. Assim, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo sua pena-base em: (i) R\$ 225.000,000 (duzentos e vinte e cinco mil reais), por violação ao art. 170, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 e ao art 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e (ii) R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976.

83. Em relação às circunstâncias atenuantes alegadas pela defesa, no que tange a “ausência de prejuízo ao mercado ou aos demais acionistas” e “ausência de dolo”, noto que não foi apontado pela SEP qualquer prejuízo decorrente da conduta dos Acusados, assim como em relação à ausência de dolo, talvez por não se tratar de elemento característico das infrações objeto da imputação aos Acusados, tal matéria não chegou a ser abordada pela Acusação. No que tange à alegada prestação de informações acerca da materialidade das infrações, entendo que a mera verificação da Proposta da Administração e dos documentos relacionados ao Aumento de Capital já é suficiente para a constatação da referida materialidade, não obstante as respostas fornecidas aos Ofícios da CVM. Desta forma, não acolho as circunstâncias atenuantes alegadas pela defesa.

84. De toda forma, no caso de Luiz Baumart⁴⁵, considerarei, como circunstância atenuante, seus bons antecedentes, de modo a reduzir, em 15%, os valores das penas-base a serem aplicadas⁴⁶. Ricardo Mottin, por sua vez, já foi condenado pelo Colegiado, o que impede o reconhecimento de atenuante por bons antecedentes, ainda que tal fato não caracterize reincidência nem agravante de penalidade⁴⁷. Por fim, quanto a Ernani Catalani, entendo não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

85. Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de:

sociais findos em 31.12.2009 e 31.12.2010; e pela elaboração intempestiva da proposta da administração para a assembleia geral ordinária realizada em 13.3.2015, em descumprimento do disposto no art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM nº 480/09, c/c o art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 481/09).

⁴⁴ “Art. 61 (...) § 1º Nas hipóteses de reincidência, poderá ser aplicada multa de até o triplo dos valores fixados nos incisos I a IV do caput.”

⁴⁵ Luiz Baumart não possui nenhum outro processo em curso na CVM (cf. Ficha de Antecedentes emitida em 05.04.2021 pela Divisão de Controle de Processos Administrativos – CCP).

⁴⁶ Cf. PAS CVM nº 19957.007552/2016-43, Dir. Rel., Flávia Perlingeiro j. em 29.09.2020 e PAS CVM nº 19957.009878/2019-58, Dir. Rel., Flávia Perlingeiro j. em 02.02.2021.

⁴⁷ Apesar Ricardo Mottin ter sido condenado à penalidade de multa pela CVM em 29.09.2020 no âmbito do PAS CVM nº 19957.007552/2016-43, tal condenação não foi definitiva e está pendente de recurso (cf. Ficha de Antecedentes emitida em 05.04.2021 pela Divisão de Controle de Processos Administrativos – CCP).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a) Ricardo Mottin:

a.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976 e art 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e

a.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976;

b) Ernani Catalani:

b.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), por violação ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976 e art 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e

b.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976;

c) Luiz Baumart

c.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), por violação ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976 e art 2º, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480/2009; e

c.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), por violação ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO PTE

(Doc. SEI nº 1255259)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1255259.

MARCELO BARBOSA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 05/05/2021, às 16:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1255260** e o código CRC **3894C219**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1255260** and the "Código CRC" **3894C219**.*